

제36장

제소전화해

1. 의 의

‘제소전화해’란 일반 민사분쟁이 소송으로 발전하는 것을 방지하기 위하여 소제기 전에 지방법원 단독판사 앞에서 화해를 성립시키는 절차를 말한다. 이는 소송계속 전에 소송을 예방하기 위한 화해인 점에서 소송계속 후에 그 소송을 종료시키기 위한 화해인 소송상의 화해와는 구별되나 그 법적 성질, 요건 및 효력 등에 있어서는 소송상의 화해의 법리가 그대로 적용된다. 소송상의 화해에 관하여는 제30장(소송의 종료) 제4절 참조. 흔히 이 두 가지 화해를 재판상의 화해라고 통칭하여 민법상의 화해계약(민법 731조 이하)과 구별하는 것이 보통이다.

이 제도의 본래 취지는 위와 같이 현존하는 ‘민사분쟁’의 해결을 위한 것이지만, 실제로는 이러한 목적보다도 이미 당사자 간에 성립된 계약내용을 법원의 조서에 기재하여 공증의 효과를 얻음과 동시에 집행권원을 얻고자 하는 목적으로 이용하는 예가 훨씬 많은 실정이다. 특히 현재 실무상으로는, 건물임대인이 임차인에 대한 계약종료 시의 건물인도의 집행권원을 확보해 두기 위하여, 그 계약 체결 무렵에 미리 신청하는 경우가 가장 많다. 따라서 이 경우 법원의 역할도 화해를 알선·권고하는 역할이 아니라 당사자 사이에 그러한 계약이 성립되었는지 여부와 화해조항의 내용을 확인하여 공증하는 역할에 그치고 있다.

2. 관할법원

제소전화해사건은 상대방의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원의 토지관할에 속한다(민소 385조 1항). 실무상으로 보면 양쪽 당사자의 관할합의가 되어 있는 경우가 대부분이다. 지방법원의 심판권은 법원조직법 32조에서 합의부 심판사항으로 열거되지 아니한 이상 모두 단독판사가 행하므로(법조 7조 4항), 제소전화해사건은 단독판사가 담당하게 되어 있다.

시·군법원 판사도 위 화해사건을 담당할 수 있다(법조 33조, 34조 1항 2호).

3. 신청 및 접수

가. 신청방식

신청은 서면이나 말로 할 수 있으며(민소 161조 1항), 말로 신청을 한 경우에는 법원사무관등이 조서에 그 취지를 기재하고 기명날인하여야 한다(2항, 3항). 이 경우 조서 양식은 [전산양식 A1674]와 같고, 해당 사항을 차례로 적은 뒤(385조 1항) 소정의 인지(액수에 관하여 후술)를 제출받아 조서의 말미 기타 적당한 여백에 붙이고(인지액 산출 근거를 부기하여야 함) 기명날인하면 된다.

사무의 편의를 위해서는 보통 사용되는 화해신청서 양식 용지의 해당란을 기재하여 첨부하고 조서에는 “신청인 별지와 같이 진술”이라고 기재하는 방식에 의하여도 무방하다. 이는 법관이 관여하는 절차가 아니므로 구술신청 조서에 법관의 기명날인을 받을 필요는 없고 또 신청인의 기명날인도 필요 없다.

나. 신청에 명시할 사항

(1) 신청에는 청구취지, 청구원인과 다투는 사정을 기재하여야 한다(민소 385조 1항). 이 중 청구취지와 청구원인은 필수적 명시사항으로 해석되고 있으나, 다투는 사정은 임의적 명시사항, 즉 그 명시가 없다 해서 신청이 부적법한 것으로 되지는 않는 것으로 해석되고 있다.

청구취지와 청구원인의 의미는 소장의 기재사항(민소 249조)에 관한 제16장(소의 제기) 제2절 참조. 다만 전술한 바와 같이 당사자 사이에 이미 성립한 계약에 공증 및 집행력을 얻고자 하는 대부분의 화해신청에 있어서는 청구취지에 신청인의 상대방에 대한 청구뿐 아니라 신청인이 상대방에게 하여야 하는 급여(의무)까지 함께 표시되는 경우가 많다.

다툼은 사정은 법원이 화해를 권고함에 있어서 양쪽 당사자의 의사접근 정도, 다툼의 내용, 쟁점 등을 알아두는 것이 편리하리라는 관점에서 이를

명시하도록 한 것이다. 위와 같이 이미 성립된 계약에 공증 및 집행력을 얻고자 하는 화해신청에서는 “당사자 양쪽의 의사가 접근하였다.”라는 정도로 청구원인에 이어 간단히 부기하는 것이 보통이다.

(2) 화해신청에는 그 성질에 어긋나지 아니하는 한 소에 관한 규정이 준용된다(민소 385조 4항). 따라서 신청에는 당사자와 법정대리인의 성명·주소를 명시하고(249조 1항), 준비서면에 관한 규정의 준용에 따라(2항) 작성한 날짜와 법원을 표시하고 부속서류가 있으면 그것도 붙여야 한다.

다. 인지의 부착

화해신청에는 소장에 붙일 인지액의 5분의 1의 인지를 붙여야 한다(인지 7조 1항). 즉 그 청구취지와 원인이 소장에 기재된 것으로 가상하여 소송목적의 값을 정하고 이에 따른 인지액을 산출한 후 그 5분의 1에 해당하는 인지를 붙여야 한다.

화해신청의 청구취지에 신청인의 청구권 외에 의무이행사항까지 함께 기재되는 경우에는 신청인이 자기 이익을 위하여 청구하는 부분에 대하여만 소송목적의 값을 산정하면 족하고, 피신청인의 이익을 위한 부분은 소송목적의 값 산정에 합산하지 않는다.

라. 접 수

화해신청이 있으면 민사화해사건으로 전산입력하고(인지액·편철방법예규), 사건부호(‘자’)를 붙여 사건번호를 부여하며 독립의 표지(전산양식 A1010)를 붙여서 기록을 조제한다.

마. 접수 후의 처리

소에 관한 규정이 준용되므로 접수담당 법원사무관등은 신청 또는 구술신청조서를 심사하여 필수적 기재사항의 누락, 인지의 부족 등 흠이 있으면 보

정을 권고하고(민소규 5조 3항), 신청인이 불응할 경우 법원사무관등 또는 담당 법관은 기간을 정하여 보정을 명하고 이에 불응할 때에는 담당 법관이 신청서 또는 구술신청조서를 명령으로 각하하여야 한다(민소 254조 1항, 2항 참조).

신청서 등을 적법한 것으로 인정한 때에는 법원은 즉시 신청서 등의 부분을 피신청인에게 송달하고(민소 255조 1항, 민소규 64조 2항 참조), 재판장은 화해기일을 정하여 양쪽 당사자에게 통지하여야 한다. 송달불능시에는 주소의 보정을 명하고 이에 불응할 때에는 역시 신청서 등을 각하하여야 한다(민소 255조 2항 참조).

4. 심 리

기일은 지정된 일시와 장소에서 법관이 사건과 당사자를 호명하여 양쪽 당사자를 출석시킴으로써 개시된다. 간이한 절차로 집행권원이 형성되므로 당사자의 확인이 중요하다. 당사자 본인이 신청하는 경우 대개 주민등록증 등으로 확인한다. 채권자의 폭리행위나 탈법행위를 합법화하는 수단으로 제소전화해가 활용되는 것 등을 방지할 목적으로 대리인의 선임권을 상대방에게 위임할 수 없고, 법원은 필요한 경우 대리권의 유무를 조사하기 위하여 당사자 본인 또는 법정대리인의 출석을 명할 수 있도록 정하고 있으므로(민소 385조 2항, 3항), 양쪽 당사자에 대리인이 선임되어 있는 경우에는 일단 피신청인에게 공증인, 그 밖의 공증업무를 보는 사람의 인증을 받은 위임장(89조 2항)을 제출하도록 하거나 피신청인의 인감증명서를 제출하도록 한 후 인감증명서상의 인영과 위임장상의 인영이 동일한지 여부를 확인하고, 필요한 경우에는 피신청인에게 기일통지를 하고 심문을 하여 진정한 위임 여부를 확인하여야 한다.

신청인 또는 상대방이 불출석한 때에는 다시 기일을 정하여 통지할 수도 있고 또 화해불성립으로 처리할 수도 있다(민소 387조 2항). 어느 쪽으로 처

리하든 법원의 재량에 속하는 사항이므로 관계없다. 다만 신청취하간주로 처리할 수는 없다고 해석된다(268조는 성질상 준용되지 않음). 실무상 통상 1회 불출석 시 연기, 2회 불출석 시 화해불성립으로 종결 처리하고 있다.

또 당사자의 의사가 이미 일치하여 일정한 계약이 성립된 경우에는 양쪽 당사자에게 그 계약의 진위 여부 및 그 계약내용대로의 화해성립에 관한 의사 유무를 확인하여야 하고 특히 당사자 본인의 경우에는 화해의 내용이나 법률효과 등을 잘 설명해 주는 것이 필요하다.

제소전화해조서도 준재심의 대상이 되지만(대법원 1992. 11. 27. 선고 92다 8521 판결), 화해조항의 강행법규 내지 공서양속 위반은 준재심사유가 되지 않으므로(민소 461조 참조) 화해조항이 강행법규 내지 공서양속에 위반하지 않도록 특히 주의를 기울여야 한다. 만일 화해조항이 강행법규 내지 공서양속에 위반되는 경우 당사자에게 청구취지의 정정을 명하고 이에 불응하면 화해신청을 부적법 각하하여야 한다. 위반 조항으로 들 수 있는 것으로는 1회 차임연체만으로 임차건물을 인도하기로 하는 기한의 이익 상실조항(민법 652조, 640조 참조), 청구원인상 담보목적의 가등기임에도 불구하고 정산절차에 관한 내용 없이 바로 그 본등기를 구하는 조항(가등기담보 등에 관한 법률 4조 1항, 2항 참조) 등이 있다.

그리고 화해 성립 후의 집행에 대비하여 화해조항의 불명확으로 인하여 집행불능이 되는 일이 없도록 목적물 표시가 정확한지를 확인해야 하고, 특히 건물의 일부분에 관한 인도의 경우에는 도면이 첨부되었는지를 반드시 확인하고, 도면 표시에 있어 거리·벽·구조 등으로 인도부분이 특정되어 있는지를 확인하여야 한다.

위 사항에 위반되는 조항이 있을 때에는 청구취지의 수정을 명하고 당사자가 이에 따라 청구취지를 정정할 때에는 조서에 기재하는 것보다는 신청서의 청구취지를 수정하게 하거나 청구취지 변경신청서를 제출하게 하는 것이 좋다.

이상의 절차는 신청조서[전산양식 A1661]에 기재하여야 한다. 보통은 신청인의 신청서 진술에 이어 화해의 성립 또는 불성립 등 결과만을 기재하고 있으나 법원이 특정사항의 기재를 명하면 이를 기재하여야 한다.

5. 화해의 성립

화해가 성립되면 법원사무관등은 그 기일의 조서에는 화해가 있다는 취지만을 적고, 별도의 용지에 화해조서를 작성하여야 한다. 화해조서에는 당사자와 법정대리인의 표시 및 청구의 취지, 청구의 원인, 화해조항, 화해 성립 연월일과 법원을 기재하고 판사와 법원사무관등이 기명날인하여야 한다(민소 386조, 민소규 31조). 이 화해조서의 양식은 [전산양식 A1690]과 같다.

화해조서에 청구취지와 청구원인을 기재하도록 한 이유가 그 화해에 의하여 효력을 받게 되는 권리관계의 범위, 즉 기판력의 객관적 범위를 밝혀 두려는 것이므로 화해신청서에 기재된 청구취지와 청구원인이 분명하지 아니한 때에는 당사자에게 석명하여 그 점을 분명하게 기재하여야 하고, 화해조항은 그 화해의 집행력과 기판력의 객관적 범위를 확정하는 것이므로 후일 화해조서에 의한 강제집행을 하거나, 다른 소송이 제기된 경우 화해조항에 의하여 확정된 권리관계가 무엇인가를 분명하게 알아볼 수 있도록 기재할 필요가 있다.

화해조서 작성 방식에 관하여는 소송상 화해의 경우와 동일하므로 그 부분에 관한 제30장(소송의 종료) 제4절 참조.

법원사무관등은 화해성립일부터 7일 이내에 화해조서의 정본을 양쪽 당사자에게 송달하여야 한다(민소규 56조).

화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 갖기 때문에(민소 220조) 판결에 관한 민사소송법 211조를 준용하여 조서의 경정이 허용되고, 준재심에 의하지 않고는 다룰 수 없다(대법원 1992. 11. 27. 선고 92다8521 판결). 제소전화해에 있어서는 종결될 소송이 계속되었던 것이 아니고 종결된 것은 화해절차

뿐이므로 재심사유가 있어 준재심 소에 의하여 제소전화해를 취소하는 준재심 판결이 확정된다 하여도 부활될 소송이 없음은 물론 그 화해절차는 화해가 성립되지 아니한 것으로 귀착되어 그 제소전화해에 의하여 생긴 법률관계가 처음부터 없었던 것과 같이 되는 것뿐이다(대법원 1996. 3. 22. 선고 95다14275 판결).

화해가 성립된 경우 특별한 합의가 없으면 화해비용은 당사자들이 각자 부담한다(민소 389조).

6. 화해의 불성립

가. 불성립조서의 작성 및 송달

(1) 판사가 화해의 기일에 화해를 권고하였으나 불응하는 경우에는 당사자 사이의 다툼의 상황에 따라 새로운 기일을 열어 다시 화해를 시도할 수도 있으나 바로 불성립으로 처리할 수도 있다. 또 당사자의 한쪽 또는 양쪽이 기일에 불출석한 경우도 마찬가지로임은 전술한 바와 같다.

어느 경우이든 화해불성립으로 처리된 때에는 법원사무관등은 그 취지를 조서에 기재하여야 한다(민소 387조 1항). 이 조서의 양식이나 작성방법에 관하여는 특별한 규정이 없으므로 민사소송법 153조의 형식적 기재사항을 명시한 화해기일조서에 실질적 기재사항으로서 “신청인 신청서 진술, 판사 양쪽 당사자에게 화해권고, 피신청인 위 권고에 불응, 화해 불성립” 등의 차례로 기재하면 된다.

(2) 위 화해불성립조서는 그 등본(정본이 아니다)을 양쪽 당사자에게 송달하여야 한다(민소 387조 3항). 이는 불출석한 당사자에게 불성립의 취지를 알려주는 의미가 있을 뿐 아니라 출석한 당사자에 있어서도 후술의 소제기신청을 할 수 있는 불변기간을 진행시켜 사건처리의 매듭을 짓기 위한 것이다.

나. 소제기신청

(1) 의 의

화해불성립의 경우에 당사자(신청인은 물론 피신청인 쪽에서도)는 그 분쟁을 소송으로 해결하기 위하여 소제기신청을 할 수 있다(민소 388조 1항). 적법한 소제기신청이 있으면 화해신청을 한 때에 신청인이 소를 제기한 것으로 본다(2항 전단). 어느 쪽에서 소제기신청을 하였든 간에 당초의 화해 신청인이 원고로 되고 화해 피신청인이 피고로 됨은 물론이다.

(2) 신청기간

소제기신청은 화해불성립의 조서등본을 송달받은 날부터 2주 이내에 하여야 하는데, 이 기간은 불변기간이다(민소 388조 3항, 4항).

위 조서등본의 송달 전이라도 소제기신청을 할 수 있다(민소 388조 3항 단서).

(3) 신청 및 접수

신청방식에 관하여는 특별한 제한이 없으므로 서면이나 말로 할 수 있다. 구술신청의 조서 기재방식에 관하여는 전술한 설명을 참조할 것이나 화해기일 종료 전에 소제기신청이 있을 때에는 그 기일조서의 “화해불성립” 기재에 이어 “신청인 소제기신청”으로 기재해 두면 된다.

화해신청인이 소제기신청을 하는 경우에는 소제기신청서에 화해신청서에 붙인 인지액 5분의 1을 제외한 나머지 5분의 4에 대하여 인지를 붙여야 하나(인지 7조 3항), 피신청인이 소제기신청을 한 때에는 인지를 붙이지 않는다.

서면에 의한 소제기신청을 접수하였을 때에는 문건으로 전산입력하며(인지액·편철방법예규) 사건번호 등을 부여해서는 안 되고 신청서는 화해사건기록에 가철한다.

소제기신청이 있는 경우 기록표지에 소제기신청의 표시를 고무인 등으로 하는 예도 있으나 의무적인 것은 아니다.

불변기간을 넘긴 소제기신청이 있는 경우, 화해 담당법관으로서는 소제기신청의 적부를 가릴 권한이 없다고 볼 것이므로 기록을 그대로 본안 관할법

원에 송부하여 그 법원의 판단에 맡겨야 한다.

(4) 기록의 송부

소제기신청이 있으면 소송기록을 본안의 관할법원에 송부하여야 한다(민소 388조 2항 후단). 기록송부서 양식은 [전산양식 A2222]를 수정하여 사용한다.

(5) 본안법원의 처리

소송기록을 송부받은 본안법원에서는 그 기록을 민사사건으로 전산입력하여 접수하고, 민사 제1심 사건부호(‘가합’, ‘가단’, ‘가소’)를 붙여 사건번호를 부여한 다음 민사 제1심 소송기록표지를 작성하여 기록 맨 앞에 첩하여 기록 송부서는 기록 말미에 첩해 두고 그 후에 작성 또는 접수되는 서류를 순서대로 가철해 나간다.

위 접수 이후의 사무처리는 통상의 민사 제1심 소송사건과 동일하게 한다. 먼저, 법원사무관등이 화해신청서를 심사하여 부족 인지액(소를 제기하는 경우에 소장에 붙여야 할 인지액으로부터 화해신청서에 붙인 인지액을 공제한 액)에 대한 보정권고를 하고, 보정이 되면 재판장이 변론기일지정, 당사자에 대한 기일 통지 등 절차를 진행하면 된다. 여기서 피신청인이 소제기신청을 한 경우에도 법원은 원고에게 인지 추가 첨부명령을 발하게 되는데 화해신청인인 원고가 소송을 원하지 않는다면 그때 원고는 일부러 인지를 추가 첨부하지 않고 소장각하의 재판을 받으려고 할 것이므로, 피고가 반소를 제기하든지 혹은 자신이 원고를 위하여 인지를 대납하지 않으면 본안판결을 받을 수 없다.

제1회 기일에서는 원고로 하여금 청구취지를 말로 진술시키는 것이 관례이다. 화해신청서에 기재된 청구취지는 소장에 기재했을 경우의 청구취지와 달라서 판결절차에서 그대로 유지시키기 어려운 경우가 많기 때문이다. 이 단계에서 화해신청서에 기재된 청구취지 중 상대방에 대한 의무이행부분은 제외되며, 반소가 없는 한 심판대상에서 벗어나게 된다.